

1501054-41.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... deve-se desclassificar a conduta de tráfico para uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, já que não restou demonstrada a destinação dos entorpecentes. A minorante do tráfico-privilegiado deve incidir no presente caso, foi o que decidiu o STF em junho, por maioria, julgando que o crime de tráfico privilegiado de entorpecentes não tem natureza hedionda. Por esse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro - CEP 13390-000, Fone: (19) 3493-1125, Rio Das Pedras-SP - E-mail: riодaspedras@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - ASSENTADA

Processo Digital nº:

1501054-41.2021.8.26.0599 - Ordem nº 2021/000902

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2184117/2021 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, 18929361 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, 582/21/522 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, AE0086-1/2021 - Delegacia de Polícia de Rio das Pedras, 2184117 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON BARRIQUELO

Artigo da Denúncia:

*

Data da audiência

23/02/2022 às 14:00h

Réu Preso

Em 23 de fevereiro de 2022, às 14 horas, nesta cidade de Rio das Pedras, Comarca de Rio das Pedras, no Foro de Rio das Pedras, na sala de audiências da Vara Única, presente o Excelentíssimo Sr. Dr. DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO, MM Juiz de Direito, comigo escrevente. Também COMPARECERAM: O representante do Ministério Público, Dr. Eduardo Henrique Balbino Pasqua; o Réu: ROBSON BARRIQUELO, Réu Preso; o Defensor Dr. Mario Fernando Navarro; e as testemunhas: Gabriel Vasco de Toledo e Sidnei Panuci. Em seguida, com as formalidades legais, o MM Juiz de Direito passou a ouvir as testemunhas e interrogar o réu, tudo gravado por meio de sistema audiovisual, conforme mídias anexadas aos autos. Após, pelas partes foi dito que não tinham mais provas a produzir. Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça para alegações finais orais, o que foi gravado por meio de sistema audiovisual, conforme vídeo anexado aos autos. Dada a palavra ao Dr. Defensor para alegações finais orais, assim se manifestou: "Consta nos autos do inquérito

policial que no dia 7 de julho de 2021 por volta das 15 horas e 15 minutos, na avenida Prefeito Nicolau Marino, 242, conjunto habitacional Vitorio Cezarino nas imediações da E.T.C- ESCOLA TECNICA ESTADUAL DR.JORGE COURRY NA CIDADE DE Rio das Pedras-sp.Robson Barrichelo qualificados as fls 6/7 trasia consigo 3 porções de maconha sem autorização em desacordo com a determinação legal e regulamentar para distribuição;. Acusado foi denunciado às fls. pela prática do crime previsto no artigo 33, caput,c/c art/40;III ambos da Lei nº 11.343/0 O Acusado, tem 29 anos e PARAPLEGICO ', e inocente que por ora lhe é conferida. Ao contrário do alegado pelos pelos policiais civis, o acusado em momento algum confessara a prática de tráfico de entorpecentes. Prova de que o Acusado não realizou nenhum tipo de confissão está na folha 05 dos autos em que consta o termo de interrogatório do auto de prisão em flagrante, em que afirmou se manifestar somente em Juízo. Diante da quantidade e somente o tipo "maconha" resta nítido que o fim era o consumo e não o tráfico, desta feita, desde já se requer a desclassificação da presente imputação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 por não haver nos autos elementos probatórios suficientes que incriminem o acusado como incurso no tráfico de entorpecentes. Excelência, o acusado foi indiciado por supostamente ter em depósito o equivalente 3 invólucros plásticos contendo maconha, e R\$ 210,00 dinheiro referente a venda de reciclagem Os Investigadores; sé esclareceu que foi apenas encontrado 03 (sete) pacotes de maconha com o Acusado em seu depoimento em juízo, tendo somente o depoimento isolado dos Guardas Municipais, portanto, o artigo 28 também prevê a aplicabilidade do verbo "ter" para a incidência do consumo pessoal da droga, senão vejamos: "Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 1- advertência sobre os efeitos das drogas; 11- prestação de serviços à comunidade; 111- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ambos os artigos (33 e 28) dispõem sobre a guarda em depósito qualquer quantidade de droga, a única diferenciação seria somente quanto à destinação da droga mantida em depósito, se para consumo próprio ou para comercialização, nesse sentido o acusado assumiu a parte que era destinada ao seu consumo pessoal. O § 2º do supracitado artigo 28 esclarece quais os parâmetros e fatores a serem analisados pelo magistrado na determinação da destinação da droga, devendo o juiz analisar a natureza e à quantidade da substância apreendida, mas não de forma isolada, mas considerando também o contexto, local e as condições em que se desenvolveu a ação policial, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do acusado, e, ainda, a conduta e os antecedentes do Acusado. DA FALTA DE PROVAS QUANTO ELEMENTO TÍPICO DA MERCANCIA E DA DENÚNCIA EMBASADA ESTRITAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES A pergunta que a defesa coloca é bastante simples: apenas o depoimento de dois AGENTE CIVIS é o suficiente para condenar um jovem por um crime equiparado a hediondo cujo a pena varia entre 5 e 15 anos? Tudo que o Estado precisa para condenar um cidadão é a palavra de dois guardas? A presunção de inocência, princípio constitucional e garantia fundamental, pode ser abalada com tão pouco? A acusação não foi capaz de produzir uma única prova da suposta mercancia de entorpecentes a não ser o depoimento dos dois guardas municipais que deixam claro que não encontraram a quantidade volumosa com o Acusado, mas tão somente o quantidade para uso próprio. Nenhum comprador, nenhum fornecedor, nenhuma anotação da venda de drogas, nenhum ato de mercancia. Tudo que pesa contra o acusado é a notícia de que os guardas foram até o local e encontraram 7 porções junto com o acusado, o restante não guarda qualquer vínculo com o Acusado. Ora, o elemento típico do tráfico é o destino mercantil da droga. Sem a demonstração desse elemento típico, a absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP, é medida de rigor. O que se denota nos autos Excelência é que a denúncia está EXCLUSIVAMENTE pautada no depoimento dos milicianos e ainda que os mesmos gozem de fé pública, a palavra destes deve ser relativizada quando não há outras testemunhas que possam corroborar a versão apresentada pelos mesmos.

Assim, dada a precariedade dos elementos de prova, encimados simplesmente nos relatos dos guardas encarregados da prisão, salta aos olhos a dúvida sobre a materialidade delitiva do crime de tráfico. E como é sabido por todos e todas, A DÚVIDA – GERADA PELA MANIFESTA DEBILIDADE INSTRUTÓRIA - HÁ QUE SER INTERPRETADA SEMPRE EM FAVOR DO ACUSADO. Esse é o único entendimento que decorre da aplicação do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, c/c art. 6º, § 4º, IV), que está insculpido na Lei Maior pátria, sob o status de cláusula pétrea, e milita em favor de todos os acusados em processo penal, impondo sejam absolvidos sempre que não houver, como na hipótese ora em tela, prova cabal, segura da autoria delitiva. Ainda que se considere a propriedade da droga como sendo do Acusado, a lei exige a comprovação da mercancia da droga para a caracterização do delito de tráfico. Não se pode presumi-la sem que se investigue a destinação da droga. Os guardas municipais não comprovaram nenhum ato que caracterize a traficância praticado pelo Acusado! A simples quantidade de entorpecente apreendido não é suficiente para caracterizar o grave delito de que foi acusado. Ora, a forma como a droga é embalada para a venda é a mesma que é adquirida. Portanto, na pior das hipóteses, deve-se desclassificar a conduta de tráfico para uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, já que não restou demonstrada a destinação dos entorpecentes. A minorante do tráfico-privilegiado deve incidir no presente caso, foi o que decidiu o STF em junho, por maioria, julgando que o crime de tráfico privilegiado de entorpecentes não tem natureza hedionda. Por esse motivo, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), ainda, o Acusado também poderá ser beneficiado por indulto, conforme o artigo 84, inciso XII, da Constituição. Acompanhando o entendimento do Supremo, a 3. Seção do STJ estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas não constitui crime de natureza hedionda. A nova tese foi adotada de forma unânime durante o julgamento de questão de ordem com o realinhamento da posição jurisprudencial, o colegiado decidiu cancelar a Súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos recursos repetitivos. Ainda, deve também ser aplicado ao presente caso em caso de condenação a atenuante de pena nos termos do art. 65 do Código Penal, tendo em vista que o denunciado é deficiente CADEIRANTE, sendo possível também atenuante da confissão espontânea da autoria do crime: "Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (...). III - ter o agente: d) "confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;". III - DAS CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DO ACUSADO E até que houvesse sido recolhido ao cárcere trabalhava fazendo bicos conforme expus em seu depoimento em juízo. Excelência, o crime pelo qual foi autuado é desprovido de violência ou grave ameaça, e não há elementos que levem à conclusão de que o Acusado faça do crime modo de vida. Ainda, não há que se falar em periculosidade do agente ou da conduta, conceito este vago, indeterminado e nem sequer aplicável por aqui. Ligado, quando muito, a medidas de segurança. Portanto, as passagens anteriores no Juízo da Infância e Juventude não podem servir como elementos indicativos de possível personalidade desviada ou de periculosidade voltada à delinquência, mesmo porque a própria lei e tratados internacionais de direitos humanos reconhecem, na criança e adolescente, indivíduos dignos de proteção integral e com personalidade em formação. A própria ECA reconhece como estando em situação de risco às crianças e os adolescentes que, por sua própria conduta, tiverem seus direitos ameaçados ou violados. Em outras palavras, a própria prática de ato infracional, além de revelar abandono pelo Estado, pela família e pela comunidade, já é, em si própria, configuradora de uma situação de risco daqueles que o praticam,

não fazendo sentido que uma situação que própria lei reconhece como de risco e de vulneração a seus direitos possa prejudicá-los depois. Nesse sentido, a anotação por atos inflaciona não podem ser vistas como reveladoras de personalidade desviada, corrompida, deturpada, ou coisa do tipo, já que o próprio ordenamento a reconhece, relativamente ao público infanto-juvenil, como objeto de um delicado e complexo processo de formação, sendo reconhecida a condição peculiar às crianças e adolescentes como de sujeito de direitos em desenvolvimento. V- PEDIDOS Acolher a

presente tese da defesa em alegações finais para absolver o acusado do crime que lhe foi imputado na exordial nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP, por restar absolutamente comprovado a inexistência dos fatos narrados na denúncia, por se tratar de droga para consumo próprio conforme esclarecido nos autos pelo acusado; Alternativamente, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se seja decretada a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, por não existir provas de ter o réu concorrido para a infração penal, logo, não há prova suficiente para condenação no incurso do artigo 33 da Lei de Drogas; Ainda, caso os argumentos apresentados sejam julgados improcedentes, requer-se a desclassificação do delito de tráfico imputado na exordial para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; Subsidiariamente em caso dos argumentos apresentados sejam julgados improcedentes, requer-se a desclassificação do delito de tráfico imputado na exordial para o previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e que seja aplicada a redutora em sua fração máxima (2/3), bem COMO a atenuante do art. 65, do Código Penal, tendo em vista que o denunciado é menor de 21 anos, aplicando-se o regime aberto para cumprimento da pena já que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade da imposição do referido regime ao Réu primário por tráfico de drogas. Em caso de condenação, requer se a Fixação da pena base no mínimo legal. Não há, no caso em tela, circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena além do mínimo legal, observado o artigo 59, do Código Penal; Requer-se o direito de apelar em liberdade. Fica expressamente requerida a análise dos argumentos nessas alegações finais para fins de prequestionamento em eventuais aos Tribunais Superiores. Por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo ante à simples situação econômica do Acusado, evidenciada pelas condições do seu labor e pelo singelo, quase ínfimo, poder aquisitivo do mesmo, evidenciadas no transcorrer da persecução penal" Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "1. DO RELATÓRIO Trata-se de ação penal de iniciativa pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ROBSON BARRIQUELO, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo a denúncia, no dia 07 de julho de 2021, por volta das 15h15, na Avenida Prefeito Nicolau Marino, 2421, Conjunto Residencial Vitorio Cezarino, nas imediações da ETEC – Escola Técnica Estadual Dr. José Coury, no Município de Rio das Pedras/SP, o denunciado trazia consigo 03 (três) porções de maconha (massa líquida: 8,3 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinando-se as substâncias ao comércio ilícito. Notificado (fls. 128), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 133/134). A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fls. 157). Citado o réu, seguiu-se, então, audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Eis, em breve síntese, o relatório. Passo a decidir. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO A materialidade delitiva está comprovada nos autos às fls. 09/21 e 144/146. A autoria, por sua vez, é certa. De seu turno, o PC Sidnei Panucci esclareceu que: havia denúncia da DelPol de que a pessoa de "Robson" traficava em local próximo à escola agrícola; havia denúncia informal de que "Robson" era cadeirante; foram ao local investigar e se depararam com o réu em um ponto de ônibus; em conversa com o réu, ele disse que não poderia ser revistado porque era cadeirante; após algum diálogo, o imputado admitiu a prática do tráfico e entregou as drogas que trazia consigo; não havia nada com o réu indicando que a droga seria destinada ao consumo; as porções de maconha encontradas com o réu estava embaladas em filme plástico, em condição própria para a venda; o réu também trazia dinheiro em espécie consigo; a escola agrícola ficava em torno de 150m do ponto de ônibus onde o réu foi preso; havia na DelPol relatório de investigação contra o réu em virtude da suspeita da prática de tráfico por parte dele; Robson indicou um barracão em frente ao ponto de ônibus como sendo sua residência; esclarece que, depois da prisão do réu, a PM prendeu outras pessoas nesse barracão no mesmo dia, à

noite, retirando drogas do barracão. O PC Gabriel Vasco de Toledo confirmou a dinâmica descrita pelo colega de trabalho. Ele acrescentou que: havia denúncia de que um cadeirante traficava no local. Finalmente, em interrogatório, o imputado disse que: estava na rua esperando sua mulher para ir à casa da sogra; os policiais chegaram e abordaram o declarante; estava com um cigarro de fumando e outras duas "parangas"; toda as as drogas eram para seu consumo; o dinheiro tinha origem lícita; morava no barracão próximo ao local onde foi abordado; sobre a denúncia de fls. 17/19, esclarece que não sabe quem possa ter feito; perguntado pelo MM. Juiz, disse que depois que saiu da cadeia fez muitos inimigos; é cadeirante desde 18 anos. Apesar do réu negar o dolo de tráfico, há provas bastantes nesse sentido. Havia denúncia anônima apontando o réu como traficante (fls. 17/19), fato que também já era do conhecimento da Polícia Civil, como esclarecido pelas testemunhas ouvidas nesta audiência. Embora a quantidade de drogas não seja elevada, nota-se que elas não estavam em condições próprias para o consumo, como se vê da fotografia de fls. 14. Além disso, o imputado trazia consigo R\$ 210,00 em espécie, em notas fracionadas de R\$ 20,00 e R\$ 10,00, cuja origem não esclarecida. A fotografia de fls. 21, tirada no exato momento do flagrante, demonstra que em plena quarta-feira, por volta de 15h, o réu estava parado no meio da rua, sem camisa, em situação típica de quem está comercializando entorpecentes. De rigor, portanto, a condenação. O réu é reincidente, pois já foi condenado anteriormente, por duas vezes, pelo crime de tráfico de drogas (processo-crime nºs 0000389-87.2012.8.26.0511 e 0001518-25.2015.8.26.0511). Presente a recidiva, não se permite a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por expressa proibição legal. Deve incidir a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, pois, consoante a prova oral colhida e o relatório de fls. 111/113, o local da prisão do réu - que era também onde ele praticava o tráfico -, ficava próximo à ETEC - Escola Técnica Estadual Dr. José Coury, havendo ainda fortes indícios de que ele se aproveitava do movimento do estabelecimento de ensino para a prática do crime, bem como expunha seus integrantes aos riscos inerentes à traficância.

3. DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei de Drogas, c.c. art. 40, III, do mesmo diploma legal e art. 61, I, do Código Penal. Passo, doravante, a dosar a pena. Na primeira fase, início pela análise das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade das substâncias não é elevada; em relação à natureza do tóxico, não há nada digno de nota. Não há elementos nos autos para avaliar a personalidade e a conduta social do réu. Passando para as circunstâncias do art. 59 do CP, o grau de culpabilidade do réu é elevado, pois o réu praticou o crime quando estava em livramento condicional (fls. 154). A todos é exigido o comportamento conforme o Direito. Sobre aqueles que já delinquiram e ainda estão em cumprimento de pena - portanto, sob a vigia imediata do Estado -, essa exigência é ainda mais acentuada. Aquele que delinque nessas condições merece um juízo de censura mais intenso. O réu não possui maus antecedentes. A personalidade e a conduta social já foram avaliadas. A motivação do crime é o propósito de lucro fácil, circunstância já considerada pelo legislador para o estabelecimento da pena mínima cominada. As circunstâncias e as consequências do crime nada têm de especiais a justificar o aumento da pena-base. or se tratar de crime vago, incabível a valoração do comportamento da vítima. Havendo uma circunstância negativa, majoro a pena-base de 1/8 (um oitavo). Passando à segunda fase, há a agravante da reincidência. Considerando que o réu possui 02 (duas) condenações anteriores pela prática do mesmo crime que ora lhe é imputado, majoro a pena de 1/3 (um terço). Na terceira fase, majoro a pena de 1/6 (um sexto), em virtude da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, tornando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa. No tocante ao regime inicial, declaro, de modo incidental, a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, por ofensa ao princípio da individualização da pena (cf. STF, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli). A estipulação do regime inicial será feita, portanto, com fundamento no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Considerando a reincidência do réu, fixo o regime inicial fechado. À mingua de informações sobre a situação

econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 avós do salário mínimo. 4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS Mantenho a prisão preventiva, reiterando a r. decisão de fls. 74/75. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, observada a gratuidade processual, ora deferida. Decreto o perdimento do numerário em favor da União. Autorizo a destruição das drogas. Comunique-se. Expeça-se certidão de honorários. Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, com a concordância das partes. Eu, ANA LUISA LORANDI FALDA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Deseja recorrer desta sentença: sim () não (X).

ADVOGADO:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

RÉU:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu. O ilustre advogado já sai intimado para apresentação das razões recursais no prazo legal."